

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 捜査機関は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合において、被疑者を捜索するため人の住居に入る必要があるときは、住居を対象とする搜索許可状がなくても、その住居に入ることができる。
- イ. 捜査機関が搜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、差し押さえるべき物が短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあり、搜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと認められるときは、令状を呈示することなくその住居に入った後、直ちに令状を呈示して搜索をすることができる。
- ウ. 捜査機関が搜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときは、令状に夜間でも搜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り搜索をすることができる。
- エ. 捜査機関の囑託により鑑定を行う者が、鑑定のため人の住居に入る必要があるときは、自ら裁判官に令状を請求し、その発付を受けて、その住居に入ることができる。
- オ. 捜査機関が人の住居に入りその内部の状態を五官の作用により認識する処分は、住居主の承諾がある場合であっても、これを令状なく行うことは許されず、検証許可状の発付を受けて行わなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.15	令 状	正答率
予備 R1-15	正 解	84%

ア 正しい

刑事訴訟法220条1項柱書は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」と規定し、同項1号において、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の搜索をすること。」と規定している。そして、同条3項において、「第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。」と規定している。刑事訴訟法220条1項1号は、人の発見を目的とする搜索に関する規定である。その趣旨は、憲法35条の「第33条の場合を除いて」とした規定を受けて、逮捕行為により被告人を拘束する場合、現場で被告人を発見するため、搜索の令状なしに他人の住居等に入り、搜索することを許したものである。これは、刑事訴訟法126条と同趣旨のものである。

イ 正しい

最決平14.10.4（百選A5事件）は、覚せい剤取締法違反被疑事件において、被疑者に「搜索差押許可状執行の動きを察知されれば、覚せい剤事犯の前科もある被疑者において、直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあったため、ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上、来意を告げることなく、施錠された上記客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り、その後直ちに被疑者に搜索差押許可状を呈示して搜索及び差押えを実施したことが認められる。以上のような事実関係の下においては、搜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、搜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、刑法222条1項、111条1項に基づく処分として許容される。」としている。また、判例は、「同法222条1項、110条による搜索差押許可状の呈示は、手続の公正を担保するとともに、処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものであるから、令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが、前記事情の下においては、警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとるものではなく、搜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって、適法というべきである。」としている。

ウ 誤っている

本記述は、急速を要するときは、令状に夜間でも搜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り搜索をすることができる点として、誤っている。

222条3項は、「第116条及び第117条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は搜索について、これを準用する。」と規定している。そして、116条1項は、「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は搜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定し、同条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は搜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」と規定している。その趣旨は、夜間における私生活の平穏に対する侵害の重大性を考慮し、搜索等を制限したものである。

エ 誤っている

本記述は、捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が、鑑定のために人の住居に入る必要があるときは、自ら裁判官に令状を請求するとしている点で、誤っている。

225条1項は、223条1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、人の住居に入るなど168条1項に規定する処分をすることができるとしている。もっとも、鑑定処分許可状の請求権者は、検察官、検察事務官及び司法警察員であり（225条2項）、鑑定受託者自身には請求権は認められていない。鑑定処分の必要性については、専門的な判断を要するため、鑑定受託者の判断が尊重されるべきであるが、捜査機関において明らかにその必要がないと認める場合には請求すべきではないとされており、その意味で、判断権は捜査機関にあるからである。

オ 誤っている

本記述は、捜査機関が人の住居に入りその内部の状態を五官の作用により認識する処分は、住居主の承諾がある場合であっても、これを令状なく行うことは許されないとしている点で、誤っている。

実況見分とは、捜査機関が五官の作用によって、犯罪現場その他犯罪に関係のある場所、身体又は物について、真実発見のために必要がある場合、その存在及び状態を実験、認識して事実を調べる任意処分をいう。つまり、実況見分は任意処分として行われる検証である。そして、犯罪捜査規範104条1項は、犯罪の現場その他の場所において事実発見のために必要があるときは、実況見分を行わなければならないとし、実況見分を令状なく行えることを前提としている。また、実況見分を行う際には、処分を受ける場所の所有者等の承諾を必要としている（犯罪捜査規範104条2項）。したがって、住居主の承諾があれば、検証許可状の発付を受けることなく実況見分を行うことができる。

以上により、正しい記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。

